

1500296-11.2022.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... (bar de fachada que, na verdade, era ponto de tráfico de entorpecentes), e os péssimos antecedentes criminais, circunstâncias concretas obstativas da aplicação da referida minorante. 8. Ordem denegada." (STF HC 111.666/MG Rel. Min. Luiz Fuxj. 08.05.12 DJU 23.05.12).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS.

LIBERDADE PROVISÓRIA: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

2ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500296-11.2022.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500296-11.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ISAIAS RIBEIRO BELISARIO e outro

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

ISAÍAS RIBEIRO BELISÁRIO e TATIANE APARECIDA ADÃO PINTO foram denunciados por incursão no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que, no dia 10 de fevereiro de 2022, por volta das 18h50min, na Travessa Nova Jersey, 10 - Parque das Américas, nesta cidade de Mauá, os acusados, em concurso de agentes, traziam consigo e expunham à venda, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, descritas no auto de exibição e apreensão (fls. 15-6) e laudo de constatação (fls. 19-21), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Recebida a denúncia, os réus foram citados (fls. 158 e 160) e apresentaram resposta

à acusação.

Testemunhas arroladas pelas partes devidamente inquiridas. Por fim, os réus foram interrogados.

Em memoriais finais, o Ministério Público requer a procedência da ação penal, enquanto as Defesas buscam, em síntese, a absolvição ante a nulidade da prova produzida ou pela insuficiência de provas, ou, ao menos, a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 (ré Tatiane), a fixação das penas no patamar mínimo, reconhecendo-se a confissão (réu Isaías), a menoridade relativa e o tráfico privilegiado, sob regime penitenciário inicial brando, além da substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos.

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

Procede a acusação.

A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 07-10), auto de exibição e apreensão (fls. 15-6), laudo de constatação (fls. 19-21), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 169-71), laudo das anotações apreendidas (fls. 211-3) e prova oral colhida.

Comprovou-se a autoria.

Interrogados, em solo policial, os réus permaneceram em silêncio (fls. 05-6).

Sob o contraditório, Isaías admitiu a prática do narcotráfico. Disse que a casa onde foi detido pertence ao marido de Tatiane, seu conhecido, mas não sabia que ele armazenava drogas. No momento da abordagem, estava nesta residência contando dinheiro. Tatiane sabia que ele praticava o tráfico, mas não estava envolvida. Não soube explicar sobre os demais entorpecentes encontrados no local. Não viu se Tatiane estava com dinheiro (mídia digital).

Tatiane, por sua vez, afirmou que saiu do serviço e foi até a casa do seu namorado, Marcos, onde Isaías já estava. Os policiais militares invadiram o local e perguntaram sobre as drogas, porém não sabia de nada. Não estava manipulando dinheiro, nem estava com os entorpecentes. No momento da invasão, estava dormindo na sala. Acrescentou que Marcos não estava no local. Afirmou que conhecia Isaías de vista, mas não sabia o que ele fazia na casa. Declarou que mora com sua mãe e familiares, em Ribeirão Pires. A residência do seu namorado fica no caminho para o seu trabalho (mídia digital).

As versões dos réus, isoladas do conjunto probatório, não merecem prosperar.

Os policiais militares, na fase administrativa, historiaram que: (sic) "estávamos em serviço na viatura 94205, e ao chegarmos ao final da viela, avistamos um grupo de indivíduos que, ao notarem nossa presença, puseram-se a correr, razão pela qual fomos no encalço de um daqueles indivíduos, que vestia calça jeans e camiseta branca, pois percebemos que ele carregava consigo uma espécie de bolsa a tira colo; tal indivíduo acessou um corredor, por onde havia uma escadaria e, assim que entrou por uma porta de madeira, que levava a um cômodo, foi alcançado e detido por mim; enquanto eu realizava a busca pessoal nele, o Sargento incursionou por aquele cômodo e viu uma mulher sobre uma cama, percebendo que ela mantinha sobre tal cama, dinheiro em espécie, anotações em folha de caderno, bem como inúmeros invólucros que aparentavam conter drogas; ela tinha ainda um celular, da marca Motorola, portava uma bolsa, no ombro e, ao lado da referida cama, bem ao seu lado, tinha uma sacola plástica, do tipo de mercado; tanto naquela bolsa, como nessa sacola, foram achados invólucros da mesma espécie que estava em cima da cama; na busca pessoal

que realizei naquele indivíduo, identificado como sendo ISAÍAS RIBEIRO BELISÁRIO, descobri que ele transportava naquela bolsa, 65 embalagens plásticas contendo maconha, 365 microtubos, contendo cocaína e 180 embalagens plásticas, também contendo cocaína, R\$292,00, em notas trocadas e um aparelho de telefonia celular, da marca Motorola; comparando, percebemos que aquelas embalagens, achadas com ISAÍAS, eram idênticas às embalagens do entorpecente encontrado em poder da abordada, TATIANE; diante disso, foi dado voz de prisão em flagrante para ambos e, junto daquelas porções, celulares e do dinheiro apreendido" (fls. 02-4).

Em juízo, o policial militar Anderson afirmou que efetuava patrulhamento a fim de coibir o tráfico, oportunidade em que, em um ponto de venda de drogas, visualizou alguns indivíduos juntos que correram com a presença da equipe. Dentre esses indivíduos, havia um suspeito portando uma bolsa tiracolo, que foi acompanhado. Em dado momento, ele acessou um corredor e, na sequência, uma escadaria, passando por uma porta de madeira. Antes que a porta fechasse, simultaneamente ao ingresso do acusado neste local, ele foi abordado. O local era guarnecido de outros cômodos e, para garantir a segurança dos responsáveis pela abordagem, fizeram varredura do ambiente, momento em que presenciaram a acusada Tatiane sentada em uma cama, contando dinheiro. Ao lado dela, tinha uma sacola de mercado com grande quantidade de drogas e ela também portava uma bolsa tiracolo com mais entorpecentes. Na bolsa de Isaías, foram apreendidas drogas embaladas para a venda, similares àquelas encontradas com Tatiane, além de dinheiro. Informalmente, os réus nada disseram. O local da abordagem aparentava ser uma residência, mas não havia móveis, somente uma cama no segundo cômodo. Não foi apurado se aquela casa era a residência de alguém. Questionado pelo Defensor Público, novamente explicou que efetuaram a varredura do local da abordagem para a segurança da equipe, já que a região era conhecida por ser ponto de venda de drogas e poderia haver comparsas. Pela sua experiência, sabe que traficantes costumam atuar em comparsaria, muitas vezes armados e, portanto, realizaram a vistoria do cômodo anexo (mídia digital).

No mesmo sentido as declarações do policial militar Vinicius, que confirmou integralmente a dinâmica narrada pelo seu companheiro de farda. Sobre o ingresso na residência, esclareceu que o réu foi abordado no exato momento que passou pela porta, antes mesmo que ela se fechasse. Acrescentou, ainda, que foi o seu parceiro quem localizou e abordou a acusada. Ao final, fizeram a varredura do entorno do local da abordagem (mídia digital).

A prova por meio de depoimento de policiais não é desvaliosa, quanto ao actum a que corresponda, pela só condição profissional das testemunhas. Ao revés, estar-se-ia diante de uma acepção processual de pessoas com apoio em predicado genérico. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que não é causa simpliciter de menor credibilidade a circunstância de uma testemunha ser policial. Nessa linha:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07).

A testemunha de defesa Mariane, irmã da ré Tatiane, nada informou a respeito do ocorrido. Disse que a ré reside com sua mãe, em outro endereço. No dia dos fatos, a acusada trabalhou e provavelmente deve ter ido até o local, que fica no caminho de casa. Pelo que sabe, Tatiane namorava um rapaz há aproximadamente quatro meses. Não soube dizer se a ré é usuária de entorpecentes, pois nunca presenciou ela fazendo o

uso de drogas. No mais, teceu comentários sobre a boa conduta social da ré (mídia digital).

A testemunha de defesa Daniela, prima da ré Tatiane, afirmou que tem uma assistência técnica próxima ao local do ocorrido, onde a acusada presta serviços de vendedora, de segunda-feira a sábado. No sábado, ela não compareceu e, em contato com Mariane, soube da prisão. Na sexta-feira, Tatiane trabalhou até as 18h e recebeu o pagamento da semana no valor aproximado de R\$ 231,00. A acusada morava com a mãe, mas quando brigava com ela, ficava com o namorado. No mais, teceu comentários sobre a boa conduta social da ré (mídia digital).

Ao final da instrução, de rigor a condenação.

As declarações das testemunhas de defesa, parentes da ré Tatiane, devem ser tomadas com ressalvas, até porque não presenciaram o ocorrido.

De outro lado, observe-se que os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares além de plenamente coerentes, estão em perfeita harmonia àqueles por eles prestados perante a autoridade policial. Ademais, não há qualquer motivo a que não possa ser atribuído total crédito a tais depoimentos. Não há nos autos prova alguma, sequer indícios, de que tivessem motivo particular, injusto, para incriminar falsamente os réus.

Destaca-se que não houve invasão de domicílio.

Há nos autos elementos aptos a indicar que, no momento da perseguição policial, havia fundada suspeita de que o réu Isaías transportava entorpecentes, já que foi visto com uma bolsa, em local conhecido como ponto de tráfico. Ocorre que, para desvencilha-se da abordagem, o réu tentou se esconder na residência em questão, porém foi detido no exato momento em que ingressou no local. Sendo assim, certo é que havia fundada suspeita acerca da existência de drogas naquele imóvel, com o acusado, o que foi, posteriormente, confirmado pela equipe policial.

Além disso, o narcotráfico é crime permanente, permitindo-se à autoridade policial, a partir da fundada suspeita, ingressar no interior de domicílio em decorrência do estado de flagrância, sem mandado judicial ou permissão do morador (Ap. 0000990-27.2014.8.03.0006 -AP, Câmara Única, rel. Carlos Tork, 21.06.2016, v.u.).

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS [...] DOMICÍLIO - VIOLAÇÃO - FLAGRANTE - ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ALCANCE. Caracterizadas fundadas razões, prévias à realização da diligência, a indicarem, de forma concreta, a ocorrência, no momento, de crime, mostra-se lícita a entrada forçada em domicílio desprovida de autorização judicial. [...] (HC 159017, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 21/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-117 DIVULG 31-05-2019 PUBLIC 03-06-2019 - grifo nosso).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. ENTRADA AUTORIZADA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas, na modalidade de guardar ou ter em depósito, constitui crime permanente, configurando-se o flagrante enquanto o entorpecente estiver em poder do infrator, incidindo, portanto, a excepcionalidade do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, reafirmou o referido entendimento, com o alerta de que para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 3. No

caso em exame, porém, conforme se infere do acórdão impugnado do TJGO, após o recebimento de denúncia anônima sobre o intenso tráfico de drogas naquele endereço, os policiais foram em diligência averiguar o caso, e ao chegarem no local "a entrada na casa teria sido autorizada pelos moradores." A versão é a mesma contida no auto de prisão em flagrante, das declarações prestadas pelos agentes públicos. A ação policial logrou êxito na apreensão de 2 porções de maconha pesando 1,055 kg e 3 de crack pesando 0,554, além de uma balança, celular e um veículo Hyundai HB20, vermelho, placa OMT-3218, com restrição de furto e roubo. 4. São válidas as provas colhidas mediante o ingresso autorizado dos policiais no domicílio do agravante. Julgados nesse sentido. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 111.760/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019 - grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019). 2. No julgamento do RE n. 603.616, Pleno do Supremo Tribunal Federal afirmou que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 3. No caso em exame, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial encontra-se evidenciada na associação das seguintes circunstâncias narradas nos autos: I) tratar-se de acusado foragido da justiça em outra ação penal também por delito de tráfico de drogas e previamente reconhecido; II) policiais já estavam em diligência para apurar informações recebidas sobre a comercialização de entorpecentes pelo paciente utilizando determinado veículo; e III) fuga do acusado para dentro de casa após a abordagem policial, tentando escapar pela parte de trás da residência, sendo preso neste momento diante do certo realizado pelos policiais que, após, encontraram mais de 9kg de cocaína na residência. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 615.563/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021 - grifo nosso).

Afasta-se também a tese do flagrante preparado. Sobre o tema, decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça no seguinte sentido: "Não se pode falar em flagrante preparado quando a atividade policial não provoca nem induz o cometimento do crime, sobretudo em relação ao tipo do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, que é de ação múltipla, consumando-se, no presente caso, já pela conduta preexistente de transportar e trazer consigo a substância entorpecente" (AgRg no AREsp 1954924/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

No mais, a quantidade de droga encontrada e as demais circunstâncias da apreensão, tais como a variedade e a forma em que era transportada, o local da abordagem, conhecido ponto de tráfico, além do dinheiro e anotações de contabilidade localizados com os réus, trazem elementos suficientes de que eles tinham a droga para entrega a terceiros e atuavam em comparsaria. Nesses termos, afasta-se o pleito desclassificatório.

Assim, entendo que o delito de tráfico de drogas está fartamente comprovado.

Passo à fixação da pena.

Atendendo aos ditames do art. 42 da Lei 11.343/06 e do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base dos réus 1/6 acima do mínimo legal, em razão da grande quantidade de drogas apreendidas – 2.767 porções de cocaína (1.425,32g) e 432 de maconha (1.234,56g), fator que justifica a majoração da reprimenda penal, na medida em que incrementa o potencial ofensivo à saúde pública (bem jurídico tutelado pela norma penal), revelando uma maior reprovabilidade da conduta dos agentes (STF, HC 73.097, rel. Min. Maurício Corrêa, HC nº 76.543-5, rel. Min. Sydney Sanches; STJ, HC nº 35.539, rel. Min. Paulo Medina, HC nº 35.795, rel. Min. Nilson Naves, HC nº 35.159, rel. Min. Hamilton Carvalhido), perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Sobre o potencial lesivo da quantidade de cocaína apreendida:

“A cocaína pode produzir uma intoxicação grave e por vezes inesperadamente com pequenas doses. A dose letal pode estar entre 0,8 a 1,2 g para um homem de 70 kg. No entanto, fumadores de base livre reportam uso de quantidades que excedem a 1 g. Em contrapartida, há casos em que se pode ocorrer o óbito com uma dose extremamente baixa de 20 mg. Isto pode ser explicado pela ocorrência da tolerância reversa que se caracteriza ou pelo aumento da susceptibilidade ao aparecimento de convulsões em doses consideradas recreacionais ou por uma excitação aumentada obtida em doses menores em usuários crônicos, fato que pode ser explicado pela diminuição da biossíntese dos neurotransmissores, o que leva a uma potencialização dos efeitos excitatórios.” (Passagli, Marcos; Toxicologia Forense – Teoria e Prática, 5ª ed., Millennium: Campinas, 2018 – pg. 180-1).

Na segunda etapa, aumento a reprimenda de Tatiane em mais 1/6, diante da reincidência (certidão fl. 48 - proc. 10052-93.2014), totalizando 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa. No tocante ao réu Isaías, presente a atenuante da menoridade relativa (19 anos – fl. 23), a pena retorna ao patamar mínimo de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. Note-se que a ré Tatiane, maior de 21 anos à época dos fatos, não faz jus à redução nos termos pleiteados pela defesa.

Em relação ao réu Isaías, justifica-se a não incidência da atenuante da confissão, não espontânea, em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal. Isso porque a confissão de quem foi preso em flagrante, em poder dos entorpecentes, e buscou falsear a verdade, isentando sua comparsa de responsabilidade, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos.

Sobre a necessidade da espontaneidade da confissão, decota-se trecho do voto do v. acórdão proferido pelo eminente Desembargador Ricardo Dip, no julgamento da Apelação Ordinária 1.390.581-8:

"Em acréscimo, confissão do acusado, houve. Espontânea, contudo, não; a que houve, tem caráter de provocada.

É válida –recruto de votos precedentes–, é válida, repito, ainda após a controvertida Reforma do Código Penal em 1984, esta lição de Roberto Lyra:

'A espontaneidade da confissão não diz respeito, é claro, à sua prestação, em que seria redundante a referência...' (Comentários ao Código Penal, ed. Forense, Rio de Janeiro, 1958, vol. 2, n. 64).

Não fosse assim, sobejaria a lei, porque, como disse Fragoso, 'se o agente confessa sob pressão policial, fato, aliás, comum, nenhuma atenuante será aplicável' (Lições de Direito Penal, ed. Forense. Rio de Janeiro, 1994, Parte Geral, n. 345).

Na mesma linha, disse Mirabete: 'Não basta a confissão para a configuração da atenuante; é necessário que o agente, arrependido, procure a autoridade para a confissão, já que a lei não fala em ato voluntário, mas em confissão espontânea' (Manual de Direito Penal, ed. Atlas, São Paulo, 1997, vol. 1, 7.5.6).

Diz José Antonio Paganella Boschi, comentando o disposto na alínea d, inc. III, art. 65, CP: 'Foge ao sentido do texto, portanto, reconhecer a atenuante quando o

agente é preso em flagrante e não tem como negar as evidências em torno da autoria ou imputar a responsabilidade pelo fato a terceiro. Inconfundíveis confissão espontânea e confissão voluntária' (Das Penas e Seus Critérios de Aplicação, ed. Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2002, p. 273).

A espontaneidade da confissão –prevista em lei como qualificação necessária do ato confessorio para atuar como causa de atenuação penal– distingue-se da mera voluntariedade da confissão. Não se trata aí do espontâneo como o que procede de um princípio interno juxta naturam agentis, sine deliberatione (Marcelino Zalba), mas do que (disse Cathrein) procedit a principio interno –ou seja, sem provocação exterior." (TACRIM-SP –11a Câmara)

Manifestou-se, também, o Supremo Tribunal Federal quanto à incompatibilidade da atenuante da confissão espontânea com a situação de flagrância:

"CONFISSÃO ESPONTÂNEA ATENUANTE. Em se tratando de situação concreta em que ocorrida a prisão em flagrante, em razão do transporte de vultuosa quantidade de droga, descabe cogitar da atenuante da confissão espontânea, no que esta última tem como objetivo colaborar com o Judiciário na elucidação da verdade real". (HC 101.861/MS, rel. Min. Marco Aurélio, 1ª T., j. em 13.04.2011)

No mesmo julgamento, manifestou-se o Min. Luiz Fux: "Eu também entendo que confissão espontânea e flagrante é contradictio in terminis, não dá para conviver; ou confissão voluntariamente ou é preso em flagrante. Não fez favor nenhum à Justiça".

Na mesma direção, precedente do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: "Apelação- Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa- Pedido para que o réu possa recorrer em liberdade prejudicado pelo presente julgamento. Condenação mantida. Apreensão de 20 porções de maconha e 61 porções de cocaína- Conjunto probatório seguro e coeso. Dosimetria fixada com rigor- Pena fixada no mínimo legal - Pedido de compensação entre confissão e reincidência- Inadmissibilidade- Confissão que sequer foi considerada na formação do convencimento do julgador- Redutor do art. 41 da Lei de Drogas- Não cabimento- Delação após prisão em flagrante com tóxico- Ausência de colaboração efetiva. Regime inicial Fechado obrigatório para réu reincidente condenado a corporal superior a quatro anos- Sentença mantida. Recurso improvido." (TJSP, AP 1501244-55.2019.8.26.0540, Rel. Des. José Vítor Teixeira de Freitas, j. 29.06.20).g.n.

Ainda assim, a pena não poderia ser fixada aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Não deve incidir, também, no caso concreto, ao réu Isaías - Tatiane é reincidente - a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Não se desconhece que a quantidade do entorpecente, nos termos da Repercussão Geral no ARE nº 666.334/AM, rel. Min. Gilmar Mendes, deve ser ponderada em apenas uma das fases da dosimetria da pena, sob pena de bis in idem. Todavia, diante das circunstâncias do delito – réu localizado em ponto de tráfico, notoriamente dominado por facções criminosas; preso em flagrante com vasta quantidade de entorpecentes, de espécies diversas, bem como dinheiro e anotações de contabilidade do tráfico; além da falta de comprovação do exercício de atividade lícita - parece-me claro o acentuado envolvimento do acusado no comércio de drogas, ou seja, a não ocasionalidade da conduta. Acrescento, ainda, que o réu Isaías já teve representação por ato infracional julgada procedente em 2020 (cf. certidão de fl.46 - processo nº 1500039-48.2020 e consulta ao ESAJ), o que evidencia, ainda mais, sua dedicação às atividades criminosas.

Nessa linha, posiciona-se o e Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. 2. Os atos infracionais também podem ser considerados como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa e, portanto, podem ser utilizados para justificar o afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 3. Agravo regimental provido. (AgRg no REsp 1873094/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020)

Ainda sobre o redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06:

"Não há bis in idem quando o Tribunal a quo fixa a pena-base acima do mínimo em razão da quantidade e natureza da droga apreendida e afasta o redutor do art. 33 § 4º da Lei n. 11.343/2006 em razão da dedicação do paciente à atividade criminosa, que restou evidenciada pela quantidade e nocividade da droga apreendida (um quilo de maconha). Também não há bis in idem quando a quantidade e a natureza da droga são consideradas na primeira fase da dosimetria da pena e, logo depois, no momento da fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda" (STJ, AgRg no REsp 1690827 MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, I, DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. AFASTAMENTO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. ANÁLISE DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA OU DE SER INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADES NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM DENEGADA. 1. A causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da lei 11.343/06 está condicionada ao preenchimento, cumulativo, dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. [...] 3. A conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza do entorpecente, os apetrechos utilizados e as circunstâncias em que a droga foi apreendida podem constituir o amparo probatório para o magistrado reconhecer a dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes: RHC 94.806/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/04/2010; HC 116.541/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/6/2013; HC 98.366/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 5/2/2010. [...]" (STF HC 121.057/SP Rel. Min. Luiz Fux j. 25.02.14 DJU 18.03.14).

"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA, MAUS ANTECEDENTES E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PRESUNÇÃO HOMINIS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS. APTIDÃO PARA LASTREAR DECRETO CONDENATÓRIO. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. DESCABIMENTO NA VIA ELEITA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A AFASTAR A MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06, ANTE A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ORDEM DENEGADA. 1. O §4º do artigo 33 da Lei de Entorpecentes dispõe a respeito da causa de diminuição da pena nas frações de 1/6 a 2/3 e arrola os requisitos necessários para tanto: primariedade, bons antecedentes, não dedicação à atividades criminosas e não à organização criminosa. 2. Consectariamente, ainda que se tratasse de presunção de que o paciente é dedicado à atividade criminosa, esse elemento probatório seria passível de ser utilizado mercê de, como visto, haver elementos fáticos conducentes a conclusão de que o paciente

era dado à atividade delituosa. 3. O princípio processual penal do favor rei não ilide a possibilidade de utilização de presunções 'hominis' ou 'facti', pelo juiz, para decidir sobre a procedência do 'ius puniendi', máxime porque o Código de Processo Penal prevê expressamente a prova indiciária, definindo-a no art. 239 como 'a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias'. Doutrina (LEONE, Giovanni. TrattatodiDirittoProcessualePenale. v. II. Napoli: Casa EditriceDott. Eugênio Jovene, 1961. p. 161-162). Precedente (HC 96062, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-02 PP-00336). 4. Deveras, o julgador pode, mediante um fato devidamente provado que não constitui elemento do tipo penal, utilizando raciocínio engendrado com supedâneo nas suas experiências empíricas, concluir pela ocorrência de circunstância relevante para a qualificação penal da conduta. 5. A criminalidade dedicada ao tráfico de drogas organiza-se em sistema altamente complexo, motivo pelo qual a exigência de prova direta da dedicação a esse tipo de atividade, além de violar o sistema do livre convencimento motivado previsto no art. 155 do CPP e no art. 93, IX, da Carta Magna, praticamente impossibilita a efetividade da repressão a essa espécie delitiva. 6. O juízo de origem procedeu a atividade intelectual irrepreensível, porquanto a apreensão de grande quantidade de droga é fato que permite concluir, mediante raciocínio dedutivo, pela dedicação do agente a atividades delitivas, sendo certo que, além disso, outras circunstâncias motivaram o afastamento da minorante. 7. In casu, o Juízo de origem ponderou a quantidade e a variedade das drogas apreendidas (1,82g de cocaína pura, 8,35g de crack e 20,18g de maconha), destacando a forma como estavam acondicionadas, o local em que o paciente foi preso em flagrante (bar de fachada que, na verdade, era ponto de tráfico de entorpecentes), e os péssimos antecedentes criminais, circunstâncias concretas obstativas da aplicação da referida minorante. 8. Ordem denegada." (STF HC 111.666/MG Rel. Min. Luiz Fuxj. 08.05.12 DJU 23.05.12).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA: INADMISSIBILIDADE. DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO VOLTADA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA: CIRCUNSTÂNCIAS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06 E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA: IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. [...] 6. Os fatos que deram ensejo à não aplicação da causa de diminuição de pena prevista na Lei de Tóxicos são hígidos e suficientes para atestar a dedicação do Paciente às atividades criminosas. 7. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas. [...] (STF HC 109.236/SP Rel. Min. Cármen Lúcia j. 13.12.11 DJU 14.23.12).

Definem-se, assim, as condenações em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa para a ré Tatiane e 05 anos de reclusão e 500 dias-multa para o réu Isaías.

O valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica dos réus.

Registre-se que o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 44 da Lei 11.343/06, nas partes em que se vedava a concessão de liberdade provisória (HC n. 104.339, rel. Min. Gilmar Mendes) e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (HC n. 97.256, rel. Min. Ayres Britto), bem como do parágrafo 1º do art. 2º da Lei n. 8072/90, que impunha o regime inicial fechado (HC n 111.849, rel. Min. Dias Toffoli).

Todavia, a gravidade in concreto do delito, considerando a diversidade das drogas, assim como o alto potencial lesivo da cocaína para saúde pública, indica um grau

acentuado de culpabilidade, de forma que o regime inicial fechado se mostra necessário para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

"HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE COMO FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL E PARA A NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ORDEM DENEGADA. Possibilidade de fixar regime inicial fechado e de afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. Precedentes. Ordem denegada." (STF - HC 119.515/AC - Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 03.12. - DJU 10.12.13).

Não fosse suficiente, Tatiane é reincidente.

Pelo mesmo motivo, não é hipótese de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, insuficiente para prevenção e reprovação da conduta.

Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na ação penal para CONDENAR a ré TATIANE APARECIDA ADÃO PINTO, qualificada nos autos, a cumprir pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e a pagar 680 dias-multa, no unitário mínimo; e ISAÍAS RIBEIRO BELISÁRIO, qualificado nos autos, às penas de 05 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 500 dias-multa, no unitário mínimo; ambos por incursão no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Denego aos condenados o direito de recorrer em liberdade, mantidas as condições do decísium, proferido em audiência de custódia (fls.86-9), reforçado, neste momento, pela condenação.

Transitada em julgado, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados.

Após o trânsito em julgado, determino a destruição da contraprova das drogas, bolsas, sacolas e anotações apreendidas, bem como decreto o perdimento dos valores (fls. 15-6), em favor do Funad, eis que comprovadamente obtidos com a narcotraficância, nos termos dos arts. 63 e 72 da Lei n.º 11.343/2006. Expeça-se o necessário.

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella - Juiz de Direito
(assinado eletronicamente)

Mauá, 23 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA